

1514596-12.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1514596-12.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514596-12.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167644/2020 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 12341259 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 2499/20/241 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 2167644 - 37º D.P. CAMPO LIMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO FELIX DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

LEONARDO FELIX DE OLIVEIRA NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 09 de julho de 2020, por volta das 12h35min, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Avenida João Caiaffa, nº 100, Vila Sonia, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, 146 acondicionamentos de maconha, consistentes em 114,4 gramas, 14 frascos de lança-perfume, consistentes em

120 mililitros, 09 invólucros de crack, consistentes em 0,5 gramas, e 15 acondicionamentos de cocaína, consistentes em 10 gramas, para fornecer a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, assim como a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Consta da denúncia que segundo apurado, policiais civis receberam informação de que no local acima indicado, já conhecido ponto de tráfico, haveria um indivíduo realizando a venda de entorpecentes, sendo fornecido suas características físicas, assim como sua vestimenta (homem branco, magro com tatuagens nos braços, camiseta azul e branco e calça jeans).

Relata a inicial que os policiais se dirigiram ao referido endereço, na oportunidade em que identificaram o denunciado, o qual agia de maneira suspeita, uma vez que apresentou movimentação típica da mercancia ilícita, vale dizer, recebeu valores de um indivíduo desconhecido, adentrou em uma viela existente no local e retornou com entorpecente.

Narra a exordial que diante desse quadro, os policiais decidiram pela abordagem do denunciado, e já notaram um buraco na parede no início da viela supra aludida, sendo localizado em seu interior um estojo contendo os entorpecentes acima referidos, assim como a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Assim, os policiais deram voz de prisão ao denunciado, conduzindo-o em seguida à Delegacia de Polícia. Segundo a acusação, os entorpecentes foram apreendidos, sendo requerido exame pericial toxicológico. Foi juntado laudo de constatação preliminar às fls. 12/16, sendo constatado: 114,4 gramas de maconha, revelando a substância THC, relacionada na lista F2; 120 mililitros de lança perfume, revelando a substância Tricloroetileno, relacionada na lista B1; 0,5 gramas de cocaína, na forma de crack, relacionada na lista F1; e 10 gramas de cocaína, relacionada na lista F1, conforme Portaria nº 344/1998 da Anvisa, atualizada pela Portaria SPTC 143/2017.

Ao fim, é da inicial acusatória que o denunciado praticou o crime se aproveitando da situação de estado de calamidade pública, decretada na esfera Federal, Estadual e Municipal, em razão da pandemia do coronavírus, na qual a população se encontrava em quarentena.

Ao ser interrogado na fase policial, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 18).

Por decisão exarada em 10 de julho de 2020, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 44/48).

Na data de 17 de julho de 2020, a prisão preventiva outrora decretada em prejuízo do acusado foi revogada, mediante o cumprimento de algumas condições alternativas ao cárcere (fls. 64/65 e 66/67).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 17 de julho de 2020 (fls. 69/70).

O acusado foi citado pessoalmente (fls. 88/89).

Na sequência, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 92).

Aos 25 de fevereiro de 2021, o recebimento da denúncia oferecida foi ratificado (fl. 94).

Foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 19 de maio de 2022 (fls. 101/102).

O acusado foi intimado pessoalmente a comparecer à audiência supra designada (fl. 122).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, menor de 21 anos de idade, sem antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a

execução do delito, devendo existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; c) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; d) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; e) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor. Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 04), Auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), Boletim de ocorrência (fls. 09/11), Laudo de constatação (fls. 12/16), Relatório final de inquérito policial (fls. 56/57), Laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 109/112), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 220737/2020, de fls. 109/112, revelou resultado positivo para as substâncias (i) tetrahydrocannabinol (Item 1), conhecida popularmente como maconha, (ii) tricloroetileno (Item 2), (iii) cocaína. A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Thiago Magalhães dos Reis, policial civil, relatou, em síntese, que chegou uma denúncia anônima de que no local dos fatos tinha indivíduo branco, magro, tatuado, no tráfico. Realizaram breve campanha onde visualizaram o réu recebendo dinheiro de certa pessoa e entrando em um "bequinho". O comprador se evadiu e não conseguiram abordar. Encontraram um estojo em um muro e no interior desse estojo tinham entorpecentes.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Elio Gonçalves da Mota, policial civil, que narrou, em suma, que não lembra da fisionomia do rapaz e não se recorda do fato.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas. Em suma, o réu aduziu que está com 22 anos de idade. Estudou até o nono ano. Parou de estudar porque começou a trabalhar. Mora com a esposa e a filha. Está trabalhando como motoboy, de dia trabalha no aplicativo e de noite na pizzaria. Nesse dia eles chegaram, abordaram o interrogando e mais três colegas, entraram no beco e retornaram com um pacote contendo droga. Os colegas eram dois menores de idade e um maior e os três foram liberados. Do local onde reside até o local da abordagem é uma distância de 15 metros no máximo.

Ocorre que, diante dos depoimentos das testemunhas policiais e demais elementos de prova, a versão exculpatória apresentada pelo Réu, negando a autoria e alegando que foi abordado com mais três colegas restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse a sua versão. Consoante o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Segundo Julio Fabbrini Mirabete, em Processo Penal, Editora Atlas, 18ª ed. 2007, pág. 258:

"Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor

da ação penal”.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Elucidativo ainda o seguinte julgado:

“Ementa: Tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo. Acusado surpreendido pela polícia na posse de 36,2 gramas de maconha, embalada individualmente, além de uma arma de fogo com numeração raspada, em sua cintura. Palavras dos policiais coerentes e seguras, com a nota de que pequenas contradições em seus depoimentos não têm o condão de invalidá-los por completo, desde que harmônicos quanto ao principal. Prova hábil à condenação. Negativa do acusado isolada, considerando-se que a abordagem se deu cerca de três horas após ele ter saído da casa da namorada. Impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecentes. Quantidade de droga, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão a denotar que os entorpecentes se destinavam à venda. Postura de quem se valia da droga para o tráfico. (...)” (Apelação Criminal nº 10910463300. Relator: Pinheiro Franco. Comarca: São Bernardo do Campo. Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal. Data do Julgamento: 06/12/2007. Data de registro: 19/12/2007).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais civis quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e variedade das drogas apreendidas; b) pela considerável quantidade de drogas (124,9g de massa líquida e 120ml, no total); c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas; d) pelas circunstâncias da prisão; e) pela apreensão de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo e guardava as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Do afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal

No tocante à agravante de ter o agente cometido o crime em ocasião de calamidade pública, em que pese o Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020 ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), in casu, não restou demonstrado que o agente tenha se aproveitado da situação para a prática do crime de tráfico de drogas, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelo réu.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“O decreto de estado de calamidade pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo coronavírus Covid19 não autoriza automaticamente o reconhecimento da referida agravante a todos os crimes praticados enquanto perdurar a calamidade. Necessária a

existência de relação do tráfico com o estado de calamidade, valendo-se, por exemplo, o agente das facilidades que dela decorrer, que garanta a impunidade ou que o beneficie, de qualquer forma, o que não se revela nos autos.” (Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021) (grifos nossos)

No mesmo sentido: Apelação Criminal 1509934-05.2020.8.26.0228 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio Mazina Martins, de 14 de outubro de 2021, e Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021.

Assim, a circunstância agravante deve ser afastada.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, à época com 20 anos de idade, é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se infere da folha de antecedentes as fls. 85/86 e certidão a fl. 87. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 anos na data do fato, tendo à época, 20 anos de idade (fl. 9). Deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário, não ostenta qualquer antecedente criminal, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, contava com 20 anos à época dos fatos, sem antecedentes desabonadores, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

“(…) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (…”. (grifos Nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

“Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e

nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento." (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441. Relator Guilherme de Souza Nucci. São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.). (grifos nossos)

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado LEONARDO FELIX DE OLIVEIRA NASCIMENTO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 50,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado. Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA